

1502562-83.2018.8.26.0451

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/03/2022

... DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502562-83.2018.8.26.0451

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3061622/2018 - DISE-
DEL.SEC.PIRACICABA, 995507 - DISE- DEL.SEC.PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIANS DE MORAES BARBOSA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Aos 23 dias do mês de março de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) WILLIANS DE MORAES BARBOSA, a testemunha arrolada pelas partes: Sheila Mayara Matildes de Oliveira Pereira Valverde e Fabricio Antonio Elias. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) comuns(Sheila), pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s). Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Fabricio Antonio Elias.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência das partes em relação à testemunha Fabricio Antonio Elias. "Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

WILLIAMS DE MORAES BARBOSA, está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 03 de maio de 2018, por volta da 00h35min, no cruzamento da Rua Fausto Fonseca Filho com a Avenida Luciano Guidotti, bairro Água Branca, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, 08 porções de maconha, com peso líquido de aproximadamente 8,7 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, conforme laudo toxicológico de fls. 29/31, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A autoria da mesma forma, é indubitosa.

Segundo restou apurado, guardas municipais foram solicitados para comparecer ao local dos fatos, a fim de atender uma ocorrência de violência doméstica. Em diligências, os servidores deslocaram-se ao local indicado, deparando-se com o denunciado, o qual foi abordado e submetido a revista pessoal, localizando-se em sua posse 08 (oito) porções de maconha.

Ouvido na delegacia, o denunciado confessou a propriedade dos entorpecentes, os quais seriam destinados ao consumo próprio (fls. 04).

Com efeito, a testemunha Sheila Mayara Matildes de Oliveira Pereira Valverde, guarda municipal, narrou "Encontrava-se devidamente escalada para seu turno de serviço, juntamente com seu parceiro, o também guarda civil Fabrício Antônio Elias, ambos ocupantes da VTR 15, ocasião em que foram solicitados pelo COP para atenderem uma ocorrência versando sobre de maria da penha, onde o autor William de Moraes Barbosa efetuava ligações ameaçando sua esposa, de um telefone público situado no local dos fatos. que imediatamente se deslocaram para o local indicado na denúncia, onde avistaram o capturado e efetuaram a sua abordagem e em revista pessoal, foi encontrado em sua posse 08 trouxinhas de maconha. aduz a guarda civil que ao ser efetuada pesquisa no sistema Prodesp, constatou que o autor teria em seu desfavor um mandado de prisão, referente ao processo 0013946-54.2017.8.26.0451 - (CNJ), expedido em 18/10/2017, pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP, sendo elaborado um bo alusivo aos fatos, ficando o autor preso junto a cadeia anexa do 1º DP de Piracicaba" (fls. 04).

No mesmo sentido o guarda civil Fabricio Antonio Elias: "Encontrava-se escalado para seu turno de serviço, juntamente com sua parceira Sheila, ambos ocupantes da VTR 15, ocasião em que foram solicitados pelo COP para atenderem uma ocorrência versando sobre de Maria da Penha, onde o autor William de Moraes Barbosa efetuava ligações ameaçando sua esposa, de um telefone público situado no local dos fatos. que se deslocaram para o local indicado na denúncia, onde avistaram o capturado e efetuaram a sua abordagem e em revista pessoal, foi encontrado em sua posse 08 trouxinhas de maconha. que ao pesquisarmos antecedentes criminais do autor, constataram que havia em desfavor do mesmo um mandado de prisão, referente ao processo 0013946-54.2017.8.26.0451 - (cnj), expedido em 18/10/2017, pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, sendo elaborado um bo alusivo aos fatos, ficando o autor preso a disposição da justiça" (fls. 05).

Perante a autoridade policial, o réu admitiu a prática delitiva e alegou

"Encontrava-se caminhado pelo local dos fatos, pois é caminho de sua casa, momento em que foi abordado por uma viatura da guarda civil. Que estava na posse de oito trouxinhas de maconha que havia comprado de um desconhecido pelo valor de R\$ 5,00 (cinco reais) cada, pois é usuário de maconha. Que não ligou para sua esposa e nem fez ameaças e não sabia que estava procurado" (fls. 04).

Em juízo, Sheila Mayara Matildes de Oliveira Pereira Valverde, guarda municipal,

confirmou os fatos e o encontro de oito porções de maconha com o réu, que assumiu o uso próprio.

O réu confessou os fatos. Que tinha comprado a droga para uso próprio.

Diante do apurado há provas suficientes da autoria e materialidade do delito imputado na inicial.

A narrativa dos guardas municipais foi firme e uníssona em confirmar que se dirigiram ao local para apurar “denúncias” de crime envolvendo violência doméstica. No trajeto, avistaram o réu, que ostentava mandado de prisão expedido contra si. Feita abordagem, em poder dele, foram localizadas porções de “maconha”.

Assim, não há dúvidas de que o entorpecente pertencia ao réu, tendo em vista que foi apreendido em seu poder.

Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos guardas civis, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso Não bastasse, o próprio réu admitiu que trazia consigo a droga, destinada a seu consumo pessoal.

Destarte, diante do conjunto probatório, imperiosa a condenação do réu.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

O réu é reincidente (0002668-56.2017.8.26.0451), razão pela qual é adequada imposição de prestação de serviços à comunidade.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Willians de Moraes Barbosa foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 62-63), no dia 03 de maio de 2018, por volta da 00h35, no cruzamento da rua Fausto Fonseca Filho com a avenida Luciano Guidotti, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Willians trazia consigo, para consumo pessoal, 08 porções de maconha, com peso líquido de aproximadamente 8,7 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, conforme laudo toxicológico de fls. 29/31, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, guardas municipais foram solicitados para comparecer ao local dos fatos, a fim de atender uma ocorrência de violência doméstica. Em diligências, os servidores deslocaram-se ao local indicado, deparando-se com o denunciado, o qual foi abordado e submetido a revista pessoal, localizando-se em sua posse 08 (oito) porções de maconha.

Interrogado em solo policial, o réu disse que: “estava caminhado pelo local dos fatos, pois é caminho de sua casa, momento em que foi abordado por uma viatura da guarda civil. Estava na posse de oito trouxinhas de maconha que havia comprado de um desconhecido pelo valor de R\$5,00 (cinco reais) cada, pois é usuário de maconha. Não ligou para sua esposa e nem fez ameaças e não sabia que estava sendo procurado” (fls. 4).

Sheila Mayara Matildes de Oliveira Pereira Valverde, guarda municipal, narrou que: “foram solicitados pelo COP para atenderem uma ocorrência versando sobre de Maria da Penha. O autor Willians de Moraes Barbosa efetuou ligações ameaçando sua esposa, de um telefone público situado no local dos fatos. Imediatamente se deslocaram para o local indicado na denúncia, onde avistaram o capturado, efetuaram a sua abordagem

e, em revista pessoal, foi encontrado em sua posse 08 trouxinhas de maconha. Ao ser efetuada pesquisa no sistema PRODESP constou que o autor teria em seu desfavor um mandado de prisão, referente ao processo 0013946-54.2017.8.26.0451 - (CNJ), expedido em 18/10/2017, pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP. Foi elaborado um B.O. alusivo aos fatos e o autor preso junto a cadeia anexa do 1º DP de Piracicaba" (fls. 4).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda municipal Fabricio Antônio Elias (fls. 5).

Às fls. 121-126, juntada certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 0002668-56.2017.8.26.0451 - ameaça - trânsito em julgado para a Defesa em 26/6/2017; autos n.º 0016196-31.2015.8.26.0451 - ameaça - trânsito em julgado para a Defesa em 24/5/2017).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 7-8 e laudo de exame definitivo de fls. 29-31.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvida, inicialmente, Sheila Mayara Matildes de Oliveira Pereira Valverde, guarda municipal. Informou que atua na patrulha Maria da Penha e que foi acionada pela ex-mulher do réu. Ela contou que estava recebendo diversas ligações do ex-marido de números distintos. Enviou o número de telefone para a central, que identificou como sendo de um telefone público. Foram ao local e o réu estava próximo ao telefone. Ele tinha mandado de prisão em aberto. Em revista pessoal, localizaram 8 porções de maconha. Não se recorda o que o réu disse com relação à droga. Não se recorda do que o réu dizia nas ligações, mas se recorda que, à época, a ex-mulher solicitava muito a patrulha. O telefone não era próximo da casa da ex-mulher.

b) Por fim, interrogado o réu Willians de Moraes Barbosa. Confirmou que usava maconha à época dos fatos. Tinha ido comprar para uso próprio. Comprou 8 porções para durar a semana inteira. Foi abordado quando fazia por volta de 20 minutos que tinha comprado a droga e já tinha consumido 1 baseado. Estava ligando para a sua mãe, na sua cabeça, mas como estava "chapado", acabou errando o número e discando para a ex-esposa. O telefone não atendia às ligações.

- DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista que a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas foi oriunda de atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Civil Municipal. Não bastasse, a atuação da GCM em atividade de policiamento ostensivo e investigativo, por si só, também é ilícita.

Isso, porque, nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para tanto. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais, set./1991. v.671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9).

Por conseguinte, é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes, por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.

Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem, eis que, conforme relatado pelos guardas municipais, ao chegarem no local dos fatos para averiguar uma ocorrência relacionada à violência doméstica, abordaram o réu e, em revista pessoal, localizaram os entorpecentes. O averiguado, portanto, não estava em situação de flagrância.

E, ainda que superado esse argumento, considerando-se legítima a prisão em flagrante, é certo que os guardas municipais carecem de competência para efetuar a busca pessoal, atividade típica de policiamento, vez que esta não é um desdobramento automático e necessário do flagrante. Tanto que a prisão em flagrante

e a busca e apreensão são disciplinadas em seções autônomas do Código de Processo Penal, sendo que a busca pessoal somente será realizada quando houver “fundada suspeita” (CPP, art. 240, § 1º); enquanto a busca pessoal é uma medida de obtenção de prova, a prisão em flagrante é um ato pré-cautelar.

Ademais, o art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem que a busca pessoal será conduzida pela autoridade policial. Assim, ainda que as guardas municipais, em razão do disposto no art. 144 da Constituição Federal, integrem a segurança pública, é certo que não podem ser considerados “autoridades policiais”; não por outra razão, quando efetuam a prisão em flagrante, fazem-no como “qualquer do povo”, com fundamento na parte inicial do art. 301 do Código de Processo Penal. Logo, para fins do art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, os guardas municipais não se equiparam às autoridades policiais. Assim, deparando-se com uma hipótese de flagrante, os guardas municipais devem apenas efetuar a custódia do indivíduo, encaminhando-o às autoridades policiais, sendo-lhes defeso efetuar a revista pessoal do cidadão detido.

Para melhor ilustrar, cite-se o habeas corpus n. 470.937-SP, em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita a revista pessoal efetuada por agente de segurança privada. Extraí-se do referido julgado, aplicável ao presente caso por analogia, que, tal como os seguranças privados, os guardas municipais poderiam ter efetuado a custódia do indivíduo, atuando como “qualquer do povo” (CPP, art. 301), mas não a sua revista pessoal (HC 470.937-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

Em síntese, atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que, para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Assim, tem-se que a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157).

E, por via de consequência, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico são provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial, vale dizer, mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao denunciado.

Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe.

- DA ABSOLVIÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO

Caso se entenda pela licitude da atuação da GCM, de rigor a improcedência da pretensão acusatória em razão da inconstitucionalidade do tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o qual fere o disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: “Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]” (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344).

Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: "O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais" (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas.

Diante da alegação ora invocada, de rigor seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, com consequente afastamento da imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas e absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

- DA PENA

Por fim, na remota hipótese de condenação e diante da confissão, requer-se seja aplicada a pena de advertência, pois tal medida se mostra proporcional à reprovação da conduta.

Ademais, caso se entenda pela aplicação de pena diversa. Requer-se seja considerada a atenuante da confissão.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS

WILLIANS DE MORAES BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso na pena do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de maio de 2018, por volta da 00h35, no cruzamento da Rua Fausto Fonseca Filho com a Avenida Luciano Guidotti, bairro Água Branca, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, 08 porções de maconha, com peso líquido de aproximadamente 8,7 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, conforme laudo toxicológico de fls. 29/31, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais foram solicitados para comparecer ao local dos fatos, a fim de atender uma ocorrência de violência doméstica. Em diligências, os servidores deslocaram-se ao local indicado, deparando-se com o réu, o qual foi abordado e submetido a revista pessoal, localizando-se em sua posse 08 (oito) porções de maconha.

Ouvido na delegacia, o réu confessou a propriedade dos entorpecentes, os quais seriam destinados ao consumo próprio (fls. 04).

A denúncia foi oferecida (fls. 62/63), mas o réu não tinha sido localizado para citação pessoal (fls. 45 e 47), de forma que os autos foram remetidos à Justiça Comum (fls. 67), sendo determinada a notificação editalícia (fls. 72).

O réu foi notificado por edital (fls. 77), apresentou resposta escrita, na qual alegou que não há questões preliminares conhecidas no momento e as questões de mérito serão tratadas posteriormente (fls. 82/83).

A denúncia foi recebida (fls. 84), o réu citado por edital (fls. 90), sendo suspenso o processo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 95).

Posteriormente, o réu foi citado pessoalmente (fls. 118), sendo revogada a suspensão do processo (fls. 119). A Defesa ratificou a defesa prévia já apresentada (fls. 130).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 131/133).

Em audiência de instrução, foi ouvida 01 testemunha comum, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da Preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que apenas abordaram o réu depois de terem sido informados de que ele estaria efetuando ligações para a mulher, com quem não podia ter contato em razão de medida protetiva, de um telefone público. Os guardas foram ao local indicado e abordaram o réu, em razão dessa denúncia de violência doméstica, quando encontraram as porções de maconha e o conduziram à Delegacia de Polícia.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, o réu foi abordado na posse da droga, depois de ter sido indicado como a pessoa que tinha efetuado ligações de um telefone público, tentando fazer contato com a mulher, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP.[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.º 603.686/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021) Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator. (STJ - HC: 676532 SP 2021/0199414-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"O recurso comporta parcial provimento. No caso, quanto à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, inexistente ofensa aos alegados dispositivos de lei federal, pois o entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte consolidada no sentido de que, "apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão" (HC n. 286.546/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). Nesse sentido, confira-se ainda: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO

DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 525.772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, fixando a pena definitiva do paciente em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - REsp: 1940142 SP 2021/0159530-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 28/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 667413 SP 2021/0152075-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA O ATO. INEXISTÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), regulamentou o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais, bem como encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (art. 5º, II, III e IV da referida Lei). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta se amolde às hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Guardas civis municipais que foram alertados por transeunte sobre a conduta do réu, dirigiram-se ao local, observaram a prática de atos típicos de traficância e efetuaram sua prisão em flagrante delito. Ausência de ilicitude da busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e dinheiro e o início da persecução penal. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis, após denúncia de traficância, avistaram o réu Yan em movimentação típica de tráfico com dois indivíduos e o surpreenderam na posse de duas porções de cocaína, vindo a localizar, no local de onde empreendera fuga, outras cinco porções da mesma droga, idênticas, e R\$ 20,00. Silente na fase extrajudicial, apelante negou em juízo o tráfico de drogas. Negativa e versão judiciais, além de fantasiosas e inverossímeis, sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial atendido para reconhecer-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, haja vista a prática do crime durante o estado de calamidade pública da pandemia de COVID-19, mormente no caso dos autos, em que se apura crime que visa a resguardar a saúde pública. Mantido o reconhecimento da reincidência. Negada a aplicação do redutor, por vedação legal expressa. Pena majorada. REGIME PRISIONAL. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, além da gravidade concreta do delito praticado. Regime inicial fechado mantido. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal (superior a

quatro anos) e a reincidência específica do réu. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido, com provimento ao recurso ministerial para, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, redimensionar suas penas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, com expedição de ofício de recomendação em seu desfavor. (TJ-SP - APR: 15015986320208260599 SP 1501598-63.2020.8.26.0599, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 29/06/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021 - grifei).

"Pondera-se, também, que em casos como o dos autos, por ser o tráfico de drogas um delito permanente, possível é a prisão flagrancial, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal. Destarte, não há impedimento legal para que membro da Guarda Civil Metropolitana efetue prisões em flagrante. Nesse sentido é a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. [...] 8. Ordem denegada. (HC 583.610/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...] III - O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). IV - Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes." (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática de tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal). 2. Recurso improvido. (RHC 20.714/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2007, DJe 04/08/2008). (TJ-SP - RVCR: 22502921020198260000 SP 2250292-10.2019.8.26.0000, Relator: João Morenghi, Data de Julgamento: 29/06/2021, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021- grifei).

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Preliminar de nulidade - Ilegalidade da prisão, efetuada por guardas civis - Réus em situação de flagrância, cuja prisão pode ser efetuada por qualquer pessoa - Artigo 301 do CPP - Preliminar rejeitada - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de significativa quantidade de maconha em poder dos acusados - Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Penas-base fixadas em seus patamares mínimos - Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo nas penas -

Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado mantido - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Rejeitada a preliminar, recursos de apelação desprovidos. Apelação da Justiça Pública - Associação para o tráfico de drogas - Fragilidade do conjunto probatório - Circunstâncias que parecem indicar mero concurso eventual de agentes e não associação de cunho permanente - Absolvição mantida - Colaboração com o tráfico de drogas na condição de informante - Hipótese de coautoria - Ré que decidiu atuar na venda de drogas em comparsaria com sua companheira, havendo a divisão de tarefas e de lucros entre ambas - Crime subsidiário aplicável somente à colaboração eventual e desvinculada do efetivo comércio de entorpecentes - Condenação pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 - Pena-base fixada em seu patamar mínimo - Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo na pena - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15029258520198260079 SP 1502925-85.2019.8.26.0079, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 25/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2021)

II - Do mérito

No mérito, a procedência da ação é de rigor.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 29/31, segundo o qual foi detectada a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC) no material apreendido.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser imputada ao réu.

Na fase policial, o réu afirmou que se encontrava caminhado pelo local dos fatos, pois é caminho de sua casa, momento em que foi abordado por uma viatura da Guarda Civil. Estava na posse de oito trouxinhas de maconha que havia comprado de um desconhecido pelo valor de R\$ 5,00 (cinco reais) cada, pois é usuário de maconha. Não ligou para sua esposa e nem fez ameaças e não sabia que estava procurado (fls. 04).

Em Juízo, o réu explicou que naquela época, estava utilizando maconha, coisa que não faz mais há muito tempo. Tinha ido comprar para uso seu. As 08 porções de maconha durariam a semana toda. Já tinha comprado a droga há 15 ou 20 minutos, quando foi abordado. Estava tentando ligar para a sua mãe e não para sua ex-mulher. Acabou ligando para a ex-esposa, porque não estava bem. Na sua cabeça, estava ligando para a mãe e não para a ex-esposa, que não o atendia. Foi abordado e estava tentando ligar para o número. Foi abordado e foi levado, em razão do mandado que existia e nem tinha conhecimento.

A confissão encontra amparo na prova produzida nos autos. Vejamos.

A guarda municipal Sheila Mayara Matildes de Oliveira Pereira Valverde aduziu que trabalha na patrulha Maria da Penha e acompanhavam a ex-mulher do réu. Tiveram uma solicitação, foram até a casa da mulher do réu, que disse que ele estava efetuando várias ligações para ela, de telefone público. Durante a conversa, o réu ligou e conseguiram encontrar o endereço do telefone público que o réu usava, para fazer a ligação. Foram até o lugar e encontraram o réu. Em revista pessoal, encontraram 08 porções de maconha, com o réu. Pesquisado, constataram que o réu era procurado. Não sabe o que o réu disse sobre a droga apreendida. Recorda-se que a ex-mulher solicitava muitas vezes a Patrulha Maria da Penha.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o guarda municipal Fabricio Antônio Elias

explicou que se encontrava escalado para seu turno de serviço, juntamente com sua parceira Sheila, ambos ocupantes da VTR 15, ocasião em que foram solicitados pelo COP para atenderem uma ocorrência versando sobre de Maria da Penha, onde o réu Willians de Moraes Barbosa efetuava ligações ameaçando sua esposa, de um telefone público situado no local dos fatos. Deslocaram-se para o local indicado na denúncia, onde avistaram o réu e efetuaram a sua abordagem. Em revista pessoal, foi encontrado em sua posse 08 trouxinhas de maconha. Ao pesquisarem antecedentes criminais do réu, constatarem que havia em desfavor do mesmo um mandado de prisão, referente ao processo 0013946-54.2017.8.26.0451 - (CNJ), expedido em 18/10/2017, pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, sendo elaborado um B.O. alusivo aos fatos, ficando o réu preso à disposição da justiça (fls. 05).

Com efeito, a prova é certa para a condenação.

O réu, tanto em solo policial quanto em Juízo, confessou que estava na posse de 08 porções da droga, para seu consumo.

Os guardas municipais confirmaram que abordaram o réu em razão de denúncia de violência doméstica, indicando que ele estava usando um telefone público para falar com a mulher. No local dos fatos, ele foi abordado e, em revista pessoal, em seu poder, os guardas civis encontraram 08 porções de maconha. Os guardas civis ainda apuraram que contra o réu havia mandado de prisão.

Nesse sentido, a versão dos guardas civis foi corroborada pela confissão.

Nem se diga que o depoimento dos guardas civis não merece confiança, uma vez que como funcionário público, suas palavras têm validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ - Processo HC 115516/SP - Habeas Corpus 2008/0202455-3 - Rel. Min. Laurita Vaz - Órgão Julgador: Quinta Turma - Data de Julgamento: 03/02/2009 - Data de Publicação: DJe 09/03/2009).

"2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (STJ - Processo HC 149540/SP - Habeas Corpus 2009/0193981-2 - Relatora: Min. Laurita Vaz - Órgão Julgador: Quinta Turma - Data do julgamento 12/04/2011 - Data de Julgamento DJe 04/05/2011).

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. MATÉRIA NÃO-ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A não-apreciação de matéria pelo Tribunal de origem impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 2. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 3. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 4. "Aferir se a condenação por tráfico de drogas, fundada exclusivamente em

depoimentos de policiais, é ou não nula, demanda incursão na seara fático-probatória, tarefa não condizente com a via eleita, angusta por excelência, mesmo porque já fixado por esta Corte a validade daquela prova testemunhal, se foi ela confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório " (HC 8.708/RS). 5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada." (STJ - Processo HC 110869/SP - Habeas Corpus 2008/0153953-4 - Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima - Órgão Julgador: Quinta Turma - Data do Julgamento: 19/11/2009 - Data do Julgamento: DJe 14/12/2009).

Ademais, a confissão e os elementos de prova, sobretudo a apreensão de 11,1 gramas de maconha na posse do réu, indicam que ele guardava o entorpecente, para seu próprio consumo, de maneira que a conduta se subsume ao delito em apreço. Nesse sentido, a prova foi suficiente para a comprovação de que o réu estava na guarda da droga conhecida como maconha e que ela tinha como destinação o consumo próprio.

A procedência da ação, portanto, sem impõe.

3) Da inconstitucionalidade

Ainda que a Constituição Federal permita aos cidadãos liberdades individuais, o uso de entorpecentes traz repercussões com relação à própria saúde pública e, por esse motivo, o direito público se sobrepõe ao privado e o dispositivo legal é constitucional.

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO TÍPICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Este Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do RE 430.150/RJ, sedimentou orientação de que a Lei n. 11.343/06 não descriminalizou a conduta que tipificou no art. 28, que, portanto, continua a configurar crime. Ocorreu mera despenalização, assim entendida como a ausência de previsão, para o tipo, de pena privativa de liberdade como sanção. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 406.905/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Assim, nenhuma justificativa há para que se reconheça a inconstitucionalidade da norma penal.

Também não há que se falar em descriminalização da conduta, na medida em que a ausência de pena corporal apenas indica a despenalização:

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO TÍPICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Este Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do RE 430.150/RJ, sedimentou orientação de que a Lei n. 11.343/06 não descriminalizou a conduta que tipificou no art. 28, que, portanto, continua a configurar crime. Ocorreu mera despenalização, assim entendida como a ausência de previsão, para o tipo, de pena privativa de liberdade como sanção. Habeas corpus não conhecido. (HC 406.905/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado

em 07/11/2017, DJe 13/11/2017 - grifei).

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE PORTE OU POSSE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCRIMINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico desta Corte Superior, alinhado ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a condenação definitiva anterior pela prática da conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, gera reincidência, porquanto essa conduta foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada (abolitio criminis). Precedentes. 2. Agravo regimental